

1500477-08.2022.8.26.0024

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... se recorda a cidade.

FATO TÍPICO:

(Tráfico de drogas - "transportar")

A autoria quanto ao tráfico é certa no tocante aos acusados WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA e MARCELO LUIZ DE JESUS.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

1ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500477-08.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500477-08.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076741/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 23726671 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2076741 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marcelo Luiz de Jesus e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo

contra WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, e MARCELO LUIZ DE JESUS, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, artigo 35, caput, e artigo 28, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 20/03/2022, por volta das 08 horas, na Rodovia SP 563, km 207, nesta cidade e Comarca de Andradina, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros 796 (setecentos e noventa e seis) tijolos da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso total aproximado de 636,40235 Kg, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, em data e horário incertos, mas antes dos fatos acima descritos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ademais, que, no dia 20/03/2022, por volta das 08 horas, na Rodovia SP 563, km 207, nesta cidade e Comarca de Andradina, trazia consigo, para uso próprio, 02 (dois) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso total aproximado de 3,3 gramas, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória narrou que: "Segundo o apurado, em data, horário e local incertos, porém em momento anterior a 20 de março de 2022, nesta cidade e comarca de Andradina, WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA e MARCELO LUIZ DE JESUS associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de entorpecente. De maneira estável e organizada, passaram a adquirir entorpecentes e revendê-los a usuários da região de Andradina. Na data e local dos fatos, policiais militares realizavam a operação "Paz e Proteção", no km 200, da Rodovia SP 563 (Integração), quando visualizaram a aproximação de dois veículos de passeio, trafegando um atrás do outro, bem rebaixados, denotando transporte de carga pesada, com placas do Estado do Paraná, motivo pelo qual deram ordem de parada, átimo em que o veículo Megane, de cor prata, que vinha na frente, não obedeceu ordem dos milicianos e, acompanhado do veículo Scenic, de cor preta, que trafegava logo atrás, seguiram o trajeto. É dos autos, ainda, que diante do ocorrido, os policiais miliares passaram a acompanhar os mencionados veículos e solicitaram apoio para outra equipe, logrando êxito, no km 207 da referida rodovia, já com a viatura de apoio, em abordar e parar os dois automóveis, oportunidade em que verificaram que veículo Megane e Scenic eram conduzidos, pelos denunciados WEVERTON e MARCELO, respectivamente. Realizadas revistas pessoais, nada de ilícito foi encontrado na posse dos denunciados, porém, ao abrirem as portas dos dois veículos, visualizaram, de imediato, vários pacotes de cor preta, com forte odor de maconha, bem como no interior do veículo Megane, em cima do banco do passageiro, havia uma folha contendo anotações do itinerário a ser feito pelos autores. Conduzidos à delegacia de polícia, verificou-se que no interior do veículo Megane, conduzido WEVERTON, havia 17 pacotes grandes, de cor preta, que envolviam o total de 476 tijolos, cada um contendo maconha prensada e envolta por fita adesiva de cor marrom, com peso aproximado de 379,25 kg, enquanto no veículo Scenic, conduzido por MARCELO, havia 12 pacotes de cor preta, contendo um total de 320 tijolos, cada um contendo maconha prensada e envolta em fita adesiva de cor marrom, com o peso total de aproximadamente 254,75 kg".

Determinada notificação para oferecimento de defesa preliminar e antecipada audiência de instrução (fls. 151/153).

Os acusados, regularmente notificados (fls. 219 e 221), ofertaram defesa preliminar (fls. 181/192).

A denúncia foi recebida, os acusados citados, e após a análise da peça defensiva, afastada possibilidade de absolvição sumária (fls. 202/204).

Sendo designada audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada de maneira semi-presencial diante das diversas providências para redução da disseminação do novo Coronavírus Covid 19, conforme Provimento nº 2.556/2020.

Produzida a prova oral, com oitiva das testemunhas. Ato contínuo, os acusados interrogados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

As partes ofertaram alegações finais.

O órgão ministerial rogou pela condenação dos acusados, nos termos da exordial.

E a Defesa postulou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 19/32), itinerário (fls. 42), laudo de constatação prévia (fls. 33/41), imagens (fls. 75/84), relatório final (fls. 130/134), laudo pericial (fls. 228/233), laudo pericial definitivo (fls. 240/245), laudo do veículo (fls. 246/256), relatório de investigação (fls. 289/291), bem como pela prova oral. Por sua vez, a responsabilidade penal dos acusados emergiram do contexto probatório, parcialmente.

DA PROVA ORAL

Em depoimento (fls. 11/12), a testemunha e policial militar Isaías dos Santos Júnior relatou que realizavam a operação "Paz e Proteção" no KM 200, da Rodovia SP 563, no momento em que visualizaram a aproximação de dois veículos de passeio, bem rebaixados, indicando transporte de carga pesada. Narrou que deram ordem de parada, entretanto os condutores não obedeceram e seguiram o trajeto. Sustentou que realizaram acompanhamento dos veículo e solicitaram apoio para outra equipe, e já com a viatura de apoio, conseguiram abordar e parar os dois veículos. Descreveu que os acusados saíram de seus respectivos veículos e ao abrirem as portas dos dois veículos, visualizaram, de imediato, vários pacotes de cor preta, com forte odor de maconha. Sustentou que no interior do veículo Megane, cor prata, em cima do banco do passageiro havia uma folha contendo anotações do itinerário a ser feito pelos infratores. Declarou que questionou os réus e ambos disseram que as drogas não eram de suas propriedades e que estariam transportando-as. Mencionou que os acusados afirmaram que ganhariam, cada um, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço. Assinalou que na porta dianteira esquerda do veículo Scenic, encontrou duas porções pequenas de maconha, envoltas em plástico, as quais o réu Marcelo disse que não lhes pertenciam. Asseverou que efetuaram a captura dos acusados e os conduziram a esta Unidade para providências de Polícia Judiciária, e foram utilizadas algemas, por fundada suspeita de fuga. Em juízo, reiterou as informações prestadas e acrescentou que os acusados relataram que receberam os entorpecentes no Paraná e levariam para Minas Gerais, bem como informaram que desconhecem a pessoa que contratou o serviço.

Em depoimento (fls. 13/14), a testemunha e policial militar Anderson de Souza Reis teve seu depoimento no mesmo sentido. Em juízo, sua oitiva foi dispensada.

Em interrogatório (fls. 15), o acusado Marcelo Luiz de Jesus optou por permanecer calado. Em juízo, esclareceu que conduzia o Scenic e confirmou que transportava o entorpecente. Declarou que não tinha a informação que o Weverton transportava entorpecente e mencionou que pegou o veículo em uma cidade de São Paulo com destino a Rio Preto/SP. Narrou que foi contratado para realizar o serviço diante do desemprego e não se recordou a quantia que receberia. Argumentou que saiu de ônibus de Goiás e a viagem durou em torno de 09 horas. Aduziu que conduziu o veículo em torno de 4 horas, saindo do posto às 4h00min e apenas visualizou Weverton neste posto.

Em interrogatório (fls. 16), o acusado Weverton Diogo Martins da Silva optou por permanecer calado. Em juízo, negou a associação ao tráfico e confirmou que conduzia o Megane, bem como alegou que não acompanhou o Marcelo, todavia saíram do mesmo local e apenas conheceu o acusado Anderson nesse local. Afirmou que foi contratado

para realizar o transporte do entorpecente diante de uma dívida com um traficante e deixaria o veículo na cidade de Ribeirão Preto/SP. Declarou que pegou o veículo no Estado de São Paulo e saiu de ônibus de Minas Gerais e desceu na rodoviária da cidade em que pegou o veículo em um posto de gasolina, porém não se recorda a cidade.

FATO TÍPICO:

(Tráfico de drogas - "transportar")

A autoria quanto ao tráfico é certa no tocante aos acusados WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA e MARCELO LUIZ DE JESUS.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório. Ademais, os denunciados confirmaram o transporte dos entorpecentes.

Os policiais militares Anderson de Souza Reis e Isaías dos Santos Júnior relataram que realizavam a operação "Paz e Proteção" no KM 200, da Rodovia SP 563, no momento em que visualizaram a aproximação de dois veículos de passeio, bem rebaixados, indicando transporte de carga pesada. Narraram que deram ordem de parada, entretanto os condutores não obedeceram e seguiram o trajeto. Sustentaram que realizaram acompanhamento dos veículos e solicitaram apoio para outra equipe, e já com a viatura de apoio, conseguiram abordar e parar os dois veículos. Descreveram que os acusados saíram de seus respectivos veículos e ao abrirem as portas dos dois veículos, visualizaram, de imediato, vários pacotes de cor preta, com forte odor de maconha. Sustentaram que no interior do veículo Megane, cor prata, em cima do banco do passageiro havia uma folha contendo anotações do itinerário a ser feito pelos infratores. Declararam, que questionou os réus e ambos disseram que as drogas não eram de suas propriedades e que estariam transportando-as. Mencionaram que os acusados afirmaram que ganhariam, cada um, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

Não há dúvida da localização dos Acusados em veículo automotor no qual localizado grande quantidade de drogas, pela diligência da polícia.

Os Acusados confirmaram a localização do estupefaciente no veículo.

Nessa toada, a conduta do acusado faz emergir o elemento subjetivo dolo, ou seja, a intenção necessária à adequação típica do fato que lhe fora imputado. No caso, o agente transportava substância entorpecente ciente da exploração proibida sem autorização ou determinação legal ou regulamentar. Portanto, caracterizada a prática criminosa acomodada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 praticada pelos denunciados.

("Associação")

A prova produzida não evidenciou que os acusados estavam associados para o tráfico de drogas, já que o vínculo associativo, de maneira estável e duradoura, como se exige, não fora demonstrado nos autos.

A simples reunião esporádica não é suficiente para caracterizar o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consigne-se que, para a doutrina e jurisprudência majoritárias, a prolação de decisão condenatória por associação para o tráfico de drogas pressupõe prova plena do vínculo estável e permanente entre os denunciados, orientado especificamente à comercialização de drogas. Ausente essa prova, ainda que existam indícios do vínculo associativo, não é possível a condenação, pois, necessária a diferenciação entre a associação para o tráfico e o concurso de agentes.

E, examinando detidamente os autos, verifico que absolutamente nada foi produzido no sentido de comprovar o imputado vínculo estável e permanente entre os acusados. No caso, a simples convergência de vontades não basta para a configuração do delito contido no artigo 35 da Lei de Tóxicos, hipótese em que restaria configurada a coautoria.

Registre-se que a descoberta casuística do delito de tráfico exercido por duas pessoas, como no caso em tela, não enseja a certeza de associação para o tráfico de drogas, uma vez que não fora demonstrado a habitualidade e permanência, essenciais para a caracterização de conduta que se amolda ao crime em comento.

Além disso, os codenunciados afirmaram que não se conheciam e apenas partiram do

mesmo local. Ademais, os acusados possuem origem distinta, já que o codenunciado WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA afirmou que era de Minas Gerais e codenunciado MARCELO LUIZ DE JESUS declarou que era de Goiás.

Nesse passo, diante da insuficiência do acervo probatório quanto à estabilidade e permanência quanto à prática do crime de tráfico de drogas, improvável a responsabilidade para a associação, não emergindo a societas criminis.

("Posse de drogas")

Quanto a imputação do crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ao codenunciado MARCELO LUIZ DE JESUS, não merece prosperar.

Cinge-se que não restou comprovado a propriedade das porções pequenas encontradas no veículo Scenic conduzido por MARCELO e ele afirmou que não lhe pertencia. Com isso, não se mostra convincente o contexto probatório para atribuir a posse de drogas para consumo pessoal.

Ainda, demonstrado o tráfico, logicamente afastado a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, diante do destino mercantil do entorpecente.

DOSIMETRIA.

-WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA.

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), sobretudo a imensa quantidade de droga apreendida (796 de maconha, com peso total aproximado de 636,40235 Kg) merecendo maior resposta por parte do Estado na aplicação da pena; quanto à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, foi aquela inerente ao crime de tráfico de drogas; o réu não possui antecedentes criminais; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime. Com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, tenho-as como desfavoráveis, visto que a atitude do réu corrobora com a criminalidade na sociedade, pois o apoio ao consumo de drogas é "desencadeador" de vários outros delitos. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima. Nestas condições, diante da imensa quantidade de drogas apreendida, essa circunstância será utilizada na primeira fase para majorar a pena base em 1/6 (UM SEXTO), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a conduta processual do acusado contribuiu relevantemente para o juízo de certeza, já que as declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação, inclusive, a sua palavra na audiência de custódia reconhecendo o transporte interestadual. Insta observar que "confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude" (RT 683/281). Logo, com a redução de 1/7 (um sétimo), fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, quanto ao tráfico entre Estados da Federação, restou configurado. Na audiência de custódia, os Acusados confirmaram o transporte interestadual com a saída da droga de um Estado com destino a São Paulo, inclusive, ocorrendo a prisão em flagrante neste município. Na audiência de instrução, no interrogatório, os Acusados mudaram a versão para afastar o tráfico interestadual. A fim de

privilegiar a palavra dos Acusados na audiência de custódia, utiliza-se o documento (fls. 42), apontou categoricamente o trajeto realizado pelos denunciados, cujo destino final se encontra na cidade de Patos de Minas/MG.

Por fim, incabível o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ("tráfico privilegiado"), porquanto a grande quantidade de entorpecente apreendida revela que os acusados se dedicava à atividades criminosas.

Nessa toada, a quantidade de droga apreendida com os acusados (peso total aproximado de 636,40235 Kg) não é usualmente confiada a traficantes neófitos, a revelar a recalcitrância na prática espúria, o que impede a aplicação da benesse acima mencionada, conforme atesta os arestos abaixo colacionado:

"APELAÇÃO - Tráfico ilícito de entorpecentes - Materialidade e autoria demonstradas. Apelante preso em flagrante, pois, em concurso com adolescente, trazia consigo maconha. Validade dos depoimentos dos policiais e testemunha presencial - Grande quantidade a evidenciar que o destino era a espúria mercancia e que se dedicava a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 - REGIME FECHADO - Crime grave, desencadeador de uma série de delitos, e equiparado a hediondo - Recurso não provido" (TJ/SP; Apelação 0010787-80.2009.8.26.0032; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 23/10/2012). (grifos meus)

"EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA APREENSÃO (...) Não incidência do redutor, tendo em vista a grande quantidade, acondicionamento, variedade, natureza da droga apreendida, além das circunstâncias que cercaram o flagrante, a indicar que não se trata de traficância inédita que pudesse qualificar os embargantes como "traficantes de primeira viagem" ou "pequenos traficantes" (o que comercializa pequena quantidade de drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de drogas a alguém que não tenha alcançado o mínimo de envolvimento dentro da cadeia do tráfico. Embargos infringentes rejeitados" (TJ-SP - EI: 00212674820188260050 SP 0021267-48.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 09/09/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos meus)

Assim, com a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando A PENA TOTAL de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PPL.

De acordo com o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, seria equivocado simplesmente efetuar-se a detração do tempo de prisão e, após, definir o regime inicial, pois, não seria observado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Impõe-se, portanto, aplicar a novel legislação em consonância com a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Desta forma, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por conta da detração, apenas será possível quando implementado o requisito objetivo indispensável à progressão de regime.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO para o acusado, conforme a redação do artigo 33, §3º, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, ainda que se trate de acusado primário, e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, b), mostra-se necessária a consideração que o legislador constituinte evidenciou, expressamente, a gravidade da conduta (art. 5, XLIII, da CF) de tráfico de drogas, especialmente, na hipótese vertente, em que transportado grande quantidade de droga.

O acusado permanece preso desde 21.03.2022, portanto, aproximadamente, 08 (oito) meses.

Feitas estas considerações, mantido aquele regime, porque não implementado o requisito temporal para a progressão de regime, qual seja, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena (= 2 anos, 8 meses e 20 dias), conforme artigo 112, inciso V, da LEP, dispositivo aplicável porque se trata de primário em crime hediondo, MANTIDO, portanto, o regime FECHADO.

SUBSTITUIÇÃO:

Logo, passo a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da substituição. São eles:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; b) o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição é suficiente.

O acusado não satisfaz os requisitos previstos no artigo supramencionado, verificando-se que a pena do crime doloso é superior a 4 (quatro) anos.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006) e deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

-MARCELO LUIZ DE JESUS.

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), sobretudo a imensa quantidade de droga apreendida (796 de maconha, com peso total aproximado de 636,40235 Kg) merecendo maior resposta por parte do Estado na aplicação da pena; quanto à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, foi aquela inerente ao crime de tráfico de drogas; o réu não possui antecedentes criminais; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime. Com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, tenho-as como desfavoráveis, visto que a atitude do réu corrobora com a criminalidade na sociedade, pois o apoio ao consumo de drogas é "desencadeador" de vários outros delitos. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima. Nestas condições, diante da imensa quantidade de drogas apreendida, essa circunstância será utilizada na primeira fase para majorar a pena base em 1/6 (UM SEXTO), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a conduta processual do acusado contribuiu relevantemente para o juízo de certeza, já que as declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação, inclusive, a sua palavra na audiência de custódia reconhecendo o transporte interestadual. Insta observar que "confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou

invocado excludente de ilicitude" (RT 683/281). Logo, com a redução de 1/7 (um sétimo), fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, quanto ao tráfico entre Estados da Federação, restou configurado. Na audiência de custódia, os Acusados confirmaram o transporte interestadual com a saída da droga de um Estado com destino a São Paulo, inclusive, ocorrendo a prisão em flagrante neste município. Na audiência de instrução, no interrogatório, os Acusados mudaram a versão para afastar o tráfico interestadual. A fim de privilegiar a palavra dos Acusados na audiência de custódia, utiliza-se o documento (fls. 42), apontou categoricamente o trajeto realizado pelos denunciados, cujo destino final se encontra na cidade de Patos de Minas/MG.

Por fim, incabível o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ("tráfico privilegiado"), porquanto a grande quantidade de entorpecente apreendida revela que os acusados se dedicava à atividades criminosas.

Nessa toada, a quantidade de droga apreendida com os acusados (peso total aproximado de 636,40235 Kg) não é usualmente confiada a traficantes neófitos, a revelar a recalcitrância na prática espúria, o que impede a aplicação da benesse acima mencionada, conforme atesta os arestos abaixo colacionado:

"APELAÇÃO - Tráfico ilícito de entorpecentes - Materialidade e autoria demonstradas. Apelante preso em flagrante, pois, em concurso com adolescente, trazia consigo maconha. Validade dos depoimentos dos policiais e testemunha presencial - Grande quantidade a evidenciar que o destino era a espúria mercancia e que se dedicava a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 - REGIME FECHADO - Crime grave, desencadeador de uma série de delitos, e equiparado a hediondo - Recurso não provido" (TJ/SP; Apelação 0010787-80.2009.8.26.0032; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 23/10/2012). (grifos meus)

"EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA APREENSÃO (...) Não incidência do redutor, tendo em vista a grande quantidade, acondicionamento, variedade, natureza da droga apreendida, além das circunstâncias que cercaram o flagrante, a indicar que não se trata de traficância inédita que pudesse qualificar os embargantes como "traficantes de primeira viagem" ou "pequenos traficantes" (o que comercializa pequena quantidade de drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de drogas a alguém que não tenha alcançado o mínimo de envolvimento dentro da cadeia do tráfico. Embargos infringentes rejeitados" (TJ-SP - EI: 00212674820188260050 SP 0021267-48.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 09/09/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos meus)

Assim, com a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando A PENA TOTAL de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PPL.

De acordo com o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, seria equivocado simplesmente efetuar-se a detração do tempo de prisão e, após, definir o regime inicial, pois, não seria observado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Impõe-se, portanto, aplicar a novel legislação em consonância com a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Desta forma, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por conta da detração, apenas será possível quando implementado o requisito objetivo

indispensável à progressão de regime.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO para o acusado, conforme a redação do artigo 33, §3º, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, ainda que se trate de acusado primário, e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, b), mostra-se necessária a consideração que o legislador constituinte evidenciou, expressamente, a gravidade da conduta (art. 5, XLIII, da CF) de tráfico de drogas, especialmente, na hipótese vertente, em que transportado grande quantidade de droga.

O acusado permanece preso desde 21.03.2022, portanto, aproximadamente, 08 (oito) meses.

Feitas estas considerações, mantido aquele regime, porque não implementado o requisito temporal para a progressão de regime, qual seja, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena (= 2 anos, 8 meses e 20 dias), conforme artigo 112, inciso V, da LEP, dispositivo aplicável porque se trata de primário em crime hediondo, MANTIDO, portanto, o regime FECHADO.

SUBSTITUIÇÃO:

Logo, passo a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da substituição. São eles:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; b) o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição é suficiente.

O acusado não satisfaz os requisitos previstos no artigo supramencionado, verificando-se que a pena a pena do crime doloso é superior a 4 (quatro) anos.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006) e deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória reconhecendo o cometimento pelo acusado WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Ainda, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória reconhecendo o cometimento pelo acusado MARCELO LUIZ DE JESUS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, tudo com fulcro no artigo 387, caput, do Código de Processo Penal. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória não reconhecendo o cometimento pelo acusado WEVERTON DIOGO MARTINS DA SILVA do delito de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), promovendo sua ABSOLVIÇÃO; ainda, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória não reconhecendo o cometimento pelo acusado MARCELO LUIZ DE JESUS dos delitos de associação e posse de drogas (artigo 35, caput, e artigo 28, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal), promovendo sua ABSOLVIÇÃO, tudo com apoio no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

MANTENHO a prisão cautelar dos acusados nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal ("O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"), conforme alteração promovida pela Lei nº 12.736/2012, pois, os réus se encontram presos em razão do presente processo e assim deverão permanecer até o trânsito em julgado desta decisão, eis que persistem os motivos que ensejaram a segregação provisória, os

quais são reforçados pela confirmação da condenação. Resumindo, RATIFICO a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do processo, recomendando-se. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance o nome dos réus no rol dos culpados.

CONCEDO a gratuidade dos Acusados. ANOTE-SE.

Custas ex legis.

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação pessoal, acompanhada de fotocópia da decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, III, da Constituição Federal.

CUMPRA-SE o disposto nos artigos 479 e 482 das NGSCGJ, com sua redação determinada pelo Provimento-CG nº 11/2015, de modo a intimar os réus para o pagamento da pena de multa e das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à Procuradoria Geral do Estado.

OFICIE-SE a autoridade policial autorizando a incineração da substância entorpecente apreendida e vinculada aos autos, caso ainda não tenha realizado.

P.I.C.

Andradina, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA